

경영관리연구
(제7권 제2호)

노사관행에 관한 실무상 문제점

최광화 | 공인노무사, 공동저자1

공유주 | 성신여자대학교 일반대학원 석사과정, 공동저자2

최근 대법원은 60여 년간 노동조합 사무실의 전기요금을 지원하여 오다가 일방적으로 이를 중단한 행위의 적법성이 다투어진 사안에 관하여 이러한 노사관행의 구속력을 인정할 수 없다는 취지의 판결을 하였다. 오랜 기간 동안 사용자가 아무런 이의제기 없이 노동조합 사무실의 전기요금을 계속적으로 부담하여 왔다면 이러한 취급에 대해서는 당사자 상호 간에 관행이 성립되었다고 평가될 수 있음에도, 대법원은 그러한 관행이 '규범의식'에 의하여 지지되어 있지 않다는 이유로 그 구속력을 부정한 것이다. 반면, 최근 대구지방법원은 사용자가 근로자들에게 정기적·계속적·일률적으로 지급하여 온 특별생산격려금의 지급에 관해서는 특별생산격려금의 지급에 관한 구속력 있는 노사관행의 성립을 긍정하였다.

이들 두 사례가 보여주는 것처럼, 법원은 노사관행의 구속력을 인정함에 있어 명확한 기준을 제시함 없이 '규범의식'이라는 모호한 기준을 근거로 그 판단을 달리하고 있는 바, 이러한 상황은 법적 안정성의 측면에서 문제라고 할 것이다.

주제어 : 노사관행, 노동관행, 사실인 관습, 관습법, 관행

I. 서론

“신분에서 계약으로”라는 말이 상징하듯 오늘날의 사회에 있어 노동력의 공급과 관련한 법률관계는 주로 노동력을 제공하는 자와 이를 제공받는 자 사이의 계약에 의해 형성되고 있다. 사법상의 계약관계는 원칙적으로 당해 계약에 명시적으로 포함된 계약조건에 의하여 주로 형성되고, 다만 이러한 계약조건에 공백이 있는 경우에 임의적 법률이 보조적으로 법률관계를 형성하는 것이 일반적인 경우인데 비하여 근로계약의 경우에는 원칙적으로 근로계약에 명시된 계약조건 이외에도 취업규칙이나 단체협약 등 다양한 형태의 준거에 의하여 근로관계의 내용이 형성된다.¹⁾ 노동법은 현실적인 노사관계부터 규범의식이 발생함으로써 생성되고, 또 그러한 생성과정을 거쳐 발전하는 것이 일반적인 경향이다. 이러한 의미에서 취업규칙이나 단체협약도 노동법의 ‘법원’의 하나로 이해되고 있는 실정이다. 나아가 경우에 따라서는 이러한 취업규칙이나 단체협약 외에 본질적으로는 반복된 사실에 불과한 노사관행에 의하여 근로관계가 형성되는 경우가 있으며, 이러한 노사관행이 법원에 의한 사법판단의 준거, 즉 재판규범으로서 작용하는 경우도 있다. 취업규칙이나 단체협약의 경우에도 그 법적 성질에 관하여 다양한 견해가 제시되고 있기는 하지만, 실정법에 취업규칙이나 단체협약의 구속력의 근거에 대한 명문규정이 마련되어 있어 이들의 규범성을 인정하는 것 자체는 크게 문제되지 않는다. 반면 노사관행의 경우에는 실정법에 그 구속력의 근거에 관한 명문규정이 없다는 점 때문에 노사관행에 근로관계를 구속하는 힘이 인정되는지(노사관행의 구속력), 나아가 그러한 힘이 인정된다면 이를 인정하는 법적 근거는 무엇인지(노사관행의 법적 성질) 등에 관하여 다양한 견해가 제시되고 있다.²⁾

노사관행의 구속력에 관한 우리나라의 판결례의 경향을 살펴보면, 최근 대구지방법원은 방송곡에서 약 10년에 이르는 기간 동안 재직 중인 근로자들에게 특별상여금 300%를 정기적·계속적·일률적으로 지급하였고, 이러한 특별상여금을 지급하기 전에 이사회 결의를 거치기는 하였으나, 임금협약에 의하여 합의된 내용대로 이사회결의가 이루어졌고, 임금협약이 없는 해에도 종전의 임금협약과 같은 내용으로 결의가 이루어졌고, 임금협약이 체결되지 않아서 지급되지 않았다가도 근로자들이 지급을 요구하자 그 다음 해에 같은 액수의 금액을 전부 지급한 등 사정이 인정되는 사안에서 “노동관행에 의해 사용자에게 지급의무가

1) 菊池高志, “勞使慣行”, 『ジュリスト 増刊: 労働法の争点, 有斐閣, 2004. 12, 24면

2) 권오성, “노사관행의 법적 성질에 관한 일고찰”, 『변호사』 제34집, 서울지방법번호사회 2004, 183면

있다”고 판단한 사례가 있다.³⁾ 위 사안에서 대구지방법원은 근로계약이나 취업규칙, 단체협약에 명문의 지급근거가 없는 특별상여금에 대하여 이러한 특별상여금이 반복적·계속적으로 지급되었다는 ‘사실’에 주목하여 사용자에게 특별상여금의 지급의무를 인정한 것이다. 반면 노동조합과 단체협약을 체결하면서 노조에 사무실을 제공하기로 했을 뿐 사무실 전기요금까지 납부한다고 명시적으로 합의하지는 않았음에도 1945년 이래 60여 년간 특별할이의 없이 노조 사무실의 전기요금을 지원해 오던 한국철도공사가 2009년 태도를 바꾸어 노조 사무실의 운영에 소요되는 전기요금납부를 거부한 사안에 대하여 이러한 전기요금지원 관행이 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되었다거나 사실상의 제도로서 확립되어 있다고 할 수 있을 정도의 규범의식에 의하여 지지되고 있었다고 보기도 어렵다고 보아 이러한 관행의 구속력을 부정한 사례가 있다.⁴⁾ 이들 두 사례를 단순히 비교해 보면 법원은 전자의 경우에는 10여년에 불과한 특별상여금 지급관행의 구속력을 인정한 반면, 후자의 경우에는 60여년에 이르는 전기요금지원 관행의 구속력을 부정하였는바, 일반적인 상식의 관점에서는 이러한 차이가 발생한 이유가 무엇인지 명확하게 설명하기 어려울 것이다. 이러한 두 사안만 보더라도 노사관행에 구속력을 인정하는 기준이 모호하여 노사관계의 당사자의 입장에서 어떠한 노사관행이 구속력이 있는 노사관행인지 여부를 알기 어렵다는 문제가 있다.

따라서 법원은 도대체 어떠한 기준으로 노사관행의 법원성의 인정여부를 판단하여왔는지 그 구체적 판단기준을 살펴보고, 그러한 일응의 판단기준이 과연 정당성이 있는가를 면밀히 검토할 필요가 있을 것이다. 본고는 아래에서 먼저 노사관행의 구속력에 관한 기존의 논의와 판결례를 분석한 후, 구속력 있는 노사관행의 성립에 관한 구체적인 기준을 검토하고, 마지막으로 이러한 법원의 판단기준의 문제점을 살펴보고자 한다.

II. 노사관행의 구속력

2.1 문제의 소재

노동관행(勞動慣行)이란 취업규칙·단체협약·근로계약 등으로 성문화되지 않은 채 노

3) 대구지방법원 2014. 9. 3. 선고 2014가단963 판결.

4) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2011다109531판결.

사관행의 현장에서 근로조건이나 직장규유 등에 관해 장기간 반복·계속 행하여진 처리방법을 의미하는 용어로 사용되는 것이 일반적이다.⁵⁾ 노사관행이 실제로 기업 내의 근로관계를 규율 내지 형성하고 있음에도 불구하고, 우리나라에서는 구속력 있는 노사관행의 성립요건에 관하여 다양한 견해가 대립하고 있고, 판례 또한 견고하지 못한 상황이다. 근로관계의 실제에 있어서 근로관계의 발생과 변경된 내용을 규율하는 규범이 존재하지 않거나 규범이 존재하지 한다고 하여도 그 내용적 틈이 발생하는 경우에 이를 보완하기 위해 특정기업 또는 사업장에는 노사관행이 발생할 수 있으며, 그렇게 발생한 노사관행은 일정기간 동안 반복됨으로써 사용자의 근로자들에게 지켜야 할 것으로 인식되고 기대되어, 규범으로서 인식의 정도 차이는 있겠지만 당사자들에게 규범으로 자리를 잡게 될 가능성이 높다.⁶⁾

이러한 노사관행의 구속력 및 그 법적 성질에 관한 견해의 대립은 우리나라의 헌법 제 103조가 “법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다.”고 규정하고 있다는 점에 비추어 과연 노사관행을 독자적인 (법)규범으로 인정할 수 있는가라는 의문에서 시작된다고 생각한다. 위 규정에 의하면 우리나라의 법제에 있어 본질적으로는 반복된 사실에 불과한 노동관행 자체에 특별한 법적 효력을 인정하는 해석론은 용이하지 않기 때문이다. 따라서, 우리나라와 같은 제정법주의국가에서 국가의 입법기관에 의하여 제정된 것이 아니라, 사회의 관행에 의하여 발생한 생활규범에 불과한 노사관행을 법규범으로 인정할 수 있겠는가라는 의문이 문제의 본질이다.

이와 관련하여 현행 민법은 제1조에서 “민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.”라고 규정하여 민사(民事)에 관한 법원으로 법률, 관습법, 조리의 세 가지를 인정하고 있는 바, 만일 노사관행이 관습법의 수준으로 인정될 수 있는 성질의 것이라면 그러한 노사관행의 법원성을 인정하는 것은 민법 제 1조의 법문에 비추어 특별히 문제되지 않을 것이다. 그러나 실제 문제가 되는 노사관행은 대부분 특정한 사용자와 그 사용자와 근로관계를 맺고 있는 일단의 근로자들 사이에서 제한적으로 성립하는 ‘사업자내 관행’이라는 점 때문에 노사관행이 관습법으로 인정되기는 어려울 것이다. 따라서 관습법의 수준에 이르는 법적 확인을 얻지 못한 상태의 노사관행에 과연 노사당사자간의 법률관계를 형성하는 구속력을 인정할 수 있는지, 나아가 그러한 구속력을 인정할 경우 구

5) 菅野和夫(이정 역), 『일본노동법』, 법문사, 2007, 89면.

6) 박수근, “노동관행의 규범성과 단체협약의 소급적 효력”, 『노동판례비평』, 민주사회를 위한 변호사 모임, 2002, 129면

속력의 근거를 어디에서 찾을 것인지가 문제되는 것이다.

노사관행의 구속력을 인정하는 근거에 관한 종래의 견해들은 크게 노사관행이 어떠한 형태로든 근로계약의 내용으로 편입되는 것으로 이해하려는 입장과 노사관행을 근로계약과는 별도로 독자적인 법원성을 인정하려는 입장으로 구분할 수 있을 것이다.⁷⁾ 이러한 견해의 차이는 근대 사법이론에 따를 경우 사인간의 법률관계의 형성은 기본적으로 당사자 사이의 의사 합치, 즉 계약에 근거하거나 국가의 입법권에 근거하여야 한다는 인식에서 비롯된 것으로 생각된다.

2.2 계약설

노사관행이 어떠한 형태로든 근로계약의 내용으로 편입된 것으로 이해하려는 입장(계약설)은 노사관행을 근로계약의 내용으로 편입시키는 방식에 따라 다시 ① 노사관행이 존재하는 경우에는 노사관계의 당사자 간에 그러한 관행의 내용을 근로계약의 조건으로 편입한다는 묵시적인 합의가 있는 것으로 보고, 이러한 묵시적 합의를 근거로 노사관행의 구속력을 인정하려는 입장(묵시적 합의설), ② 노사관행을 민법 제 106조의 사실인 관습으로 이해하고, 이러한 사실인 관습으로서의 노사관행이 근로계약이라는 법률행위의 내용으로 편입된다고 이해하려는 입장(사실인 관습설)으로 구분된다.⁸⁾ 요컨대, 계약설은 노동관행은 그 자체로서 특별한 법적 효력을 갖지 못함을 전제로, 근로조건에 관하여 일정한 취급이 이의 없이 계속 행하여져 온 경우에는 근로계약 당사자 간에 묵시적 합의가 성립한 것으로 보거나, 당사자가 이러한 ‘사실인 관습’에 따를 것을 인정한 것으로 보아 근로계약의 내용으로 편입되어 구속력이 인정된다고 이해하는 입장이다.

7) 학설대립의 상세는 寺井基博, “勞動條件の決定・變更と勞使慣行の法理”, 『講座21世紀の労働法 第3巻: 労働條件の決定と變更』, 有斐閣, 2000, 189~192면 참조.

8) 민법 제 106조는 “법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 관습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 관습에 의한다.”고 규정하고 있는바, 판례는 이러한 사실인 관습에 대하여, 사회의 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로서 승인될 정도에 이르지 않은 관습이고, 따라서 당사자가 이러한 관습을 주장·입증하여야 하며, 법률행위의 해석을 통하여 임의규정을 개폐하는 효력을 갖는 관습이라고 한다(대법원 1995. 5. 23. 선고 95다5288 판결). 참고로 사실인 관습의 성립요건에 대하여 일본 판례는 “지각, 조퇴 및 결근의 경우 임금공제를 하지 않는 것이 반복되어 당사자가 이에 따르고 있는 이상, 사실인 관습으로 고용계약의 내용이 되어 있으므로 지각을 이유로 한 임금공제는 어용될 수 없다”고 판시하고 있다.(東京地判 1971. 9. 13. 勞民集 22권 5호 106면).

1) 묵시적 합의설

이 견해는 노사관행의 구속력의 근거를 근로계약의 당사자 간의 ‘묵시적 합의’에서 찾는다. 즉, 노사 간에 특정한 행위가 법적 의무 없이 장기간에 걸쳐 반복적으로 행하여져 하나의 관행으로 존재한다면, 그러한 관행을 형성하는 개개의 행위에 대하여는 노사 간의 합의가 성립되었다고 추정할 수 있다고 하며, 나아가 이러한 노사관행을 통한 묵시적 합의의 성립이 인정되기 위해서는 경험칙상 그러한 해석이 타당하다고 인정될 수 있어야 된다고 설명한다. 다만, 묵시적 합의의 성질상 그러한 노사관행과 반대되는 명시적인 의사표시가 존재하는 경우에는 묵시적 합의의 성립을 인정하기 어려울 것이다.

2) 사실인 관습설

이 견해는 노사관행을 기업단위에서 성립하는 ‘사실인 관습’으로 이해하는 입장으로, 특정한 노사관행이 ‘사실인 관습’으로 인정될 경우 근로계약의 당사자는 이러한 ‘사실인 관습’을 준수하여야 하므로 노사관행이 근로계약의 내용으로 편입된다고 설명한다.⁹⁾

2.3 규범설

노사관행을 근로계약과는 별도의 독자적인 법원성을 인정하려는 입장(규범설)은 다시 ① 노사관행을 일종의 경영상의 관습법으로 이해하여 노사관행이 근로관계에 직접적·강행적으로 적용된다고 보는 견해(경영상 관습법설), ② 노사관행을 불문(不文)의 취업규칙으로서의 이해하여 노사관행에 취업규칙과 동등한 법적 구속력이 인정된다고 보는 견해(차용법원설), ③ 노사관행을 단체협약이나 취업규칙과 병렬적인 독자적인 법원(法源)으로 인정하여야 한다는 견해(독자적 규범설)로 구분된다.

1) 경영상 관습법설

이 견해는 노사관행 일종의 경영상의 관습법으로 파악하여 구체적인 노사관행이 마치 법규범처럼 근로관계에 직접적·강행적으로 적용된다고 보는 입장이다. 관습법은 사회구성원 사이에 일정한 행위가 반복적으로 행하여지는 관행이 존재하고, 그러한 관행이 법규범이

9) 유동적인 성격이 큰 노동법의 경우 사회 전반적인 확산에 이르지 않을 지라도 하나의 부분사회, 특히 어느 노동현장에서 어느 정도 그 구성원에게 구속력을 지니는 경우에는 그 법원성을 부정할 필요는 없으므로, 결국 노동법의 경우에는 구태여 사실인 관습과 관습법을 구별할 필요는 없다고 하는 견해가 있다.

라고 인식될 정도의 법적 확신이 사회구성원 사이에 존재하는 경우에 성립하는 바,¹⁰⁾ 노사관행이 노동관습법이 되기 위해서는 최소한 동종업종에서 사용자와 근로자 또는 노조에게 지지될 정도의 법적 확신이 필요할 것이다.

2) 차용법원설

이 견해는 노사관행에 불문의 취업규칙으로서의 성격을 부여하여 노사관행이 취업규칙 등의 기존의 법원과 동등한 법원이 된다고 이해하는 입장으로, 특정한 노사관행에 대하여 사용자와 근로자 집단과의 사이에 ‘묵시적·집단적 합의’가 존재한다고 인정할 수 있는 경우 당해 노사관행에는 불문의 취업규칙으로서 규범적 효력이 인정된다고 설명한다.

3) 독자적 규범설

이 견해는 노사관행을 단체협약이나 취업규칙 등과 나란한 독자적인 법원으로서 파악하여 그 규범적 효력을 인정하는 입장으로, 민법의 논리에 얽매이지 않고 노사관행 중 어떠한 것에 ‘법적 구속력’이 인정되어야 하는가를 탐구하여야 한다고 주장한다. 한편, 이 견해에 의하면 법적 구속력이 인정되어야 할 노사관행의 성립요건으로서 ① 집단적 노사 간(노동조합 또는 종업원집단과 사용자와의 사이)에 존재하는 관행적 사실로, ② 그 사실이 반복하여 계속되고 있고, ③ 노사 쌍방의 규범의식이 추정될 수 있을 것이라고 하는 3가지 요건을 들고 있다.¹¹⁾

4) 신뢰책임설

이 견해는 계약설과 규범설의 범주에 속하지 않은 견해로, 노사관계의 일방 당사자가 그 상대방에게 노사관행에 의하여 계속적인 급부가 행하여질 것이라는 신뢰를 발생시킨데 대한 신뢰책임을 부담한다는 데서 노사관행의 구속력의 근거를 구하는 입장이다.

5) 학설의 검토 및 평가

노사관행의 구속력에 관한 종래의 일반적인 견해는 노사관행의 구속력의 근거를 계약책임의 일종으로 이해하는 것이 주류적인 경향이라고 평가된다. 즉, 노사관행의 구속력을 노

10) 판례는 ‘민법 제1조는 관습법의 범으로서 보충적 효력을 인정하는데 반하여, 제106조는 일반적으로 사적자치에 인정되는 분야에서의 관습의 법률행위의 해석기준이나 의사보충적 효력을 인정한 것’이라고 판시하여(대법원 1983. 6. 14. 선고 80다3231판결), 관습법과 사실인 관습을 구분하고 있다.

11) 김재훈, 근로조건 변경의 범위-불이익변경의 한계를 중심으로, 서울대학교 박사학위 청구논문, 1999, 305면

사관행에 대한 당사자 사이의 묵시적 합의를 추정하거나, 노사관행을 사실인 관습으로 보아 노사관행이 당사자 사이의 법률행위를 보충한다고 이해하는 견해는 현행법이 노사관행의 구속력에 대하여 명시적 근거를 두고 있지 않다는 점을 고려할 때 노사관행의 구속력의 근거를 당사자의 의사에서 구한다는 점에서 논리구성에 무리가 없다는 장점이 있다. 다만 이러한 입장에 따를 경우 노사당사자의 일방(특히 사용자)이 기존의 노사관행에 따르지 아니한다는 취지의 의사를 명시적으로 표시하는 경우 그러한 노사관행의 구속력이 배제될 수밖에 없다는 점에서 노사관행이 갖는 집단적·조직적 성격이 약화된다는 문제가 있다. 따라서 계약설에 의할 경우에도 종래의 노사관행에 따른 급부의 유지에 대한 근로자의 신뢰가 보호될 수 있도록 하기 위하여 ‘사실인 관습’으로 성립된 노사관행의 변경 및 배제에 관하여는 일정한 제한을 가하는 것이 필요할 것이다. 구속력 있는 노사관행에 의하여 이미 발생한 권리 등의 기득권의 보호라는 측면도 고려되어야 하기 때문이다.

한편, 노사관행의 구속력의 근거를 법률행위책임에서 구하는 계약설의 입장에 따르면, 구속력 있는 노사관행의 성립을 위하여는 특정한 노사관행이 ① 동종의 행위나 사실이 장기간 반복·계속되어 보편화된 것으로(객관적 요건), ② 당사자들이 이러한 노사관행을 명시적으로 배척하지 않아 이러한 노사관행의 준수에 관한 묵시적 합의가 존재한다고 볼 수 있어야 한다(주관적 요건)는 두 가지 요건이 충족되어야 할 것이다. 한편, 구체적인 사안에 있어 특정한 노사관행이 상기 요건을 충족하여 사실인 관습으로서 인정되는지 여부는 당해 노사관행의 성립과 운영과정 전반에 관한 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

III. 노사관행의 구속력에 관한 판결례 분석

노사관행에 구속력이 인정되는지 여부 및 이러한 구속력 있는 노사관행의 성립을 인정하기 위한 요건이 무엇인지가 문제된 사안에 관한 우리나라의 법원의 판결례들을 살펴보면 판결들의 기본적인 경향은 노사관계의 영역에서의 독자적인 법원으로서의 노사관행의 개념은 인정하지 않는 입장에서 서 있는 것으로 평가된다. 즉 법원은 노동법의 영역에서의 노사관행의 특수성을 고려하기 보다는 일반 민법의 법리에 근거하여 노사관행의 법적 성격을 이해하려는 입장에서 노사관행의 구속력을 ‘사실인 관습’에서 찾는 경향을 보인다. 다만, 어떠한 경우 노사관행이 ‘사실인 관습’으로 성립하는지에 관한 구체적인 기준에 관하여는 개별 사안에 따라 일관되지 못한 판단을 하고 있다.

3.1 근로자 동의 없는 전적 관행: 대법원 1993. 1. 26. 선고 92다11695 판결(대우캐리어 사건)

대투캐리어를 비롯한 26개의 계열회사를 두고 있던 대우그룹은 그 산하에 대우인력관리 위원회를 설치하고 여기서 각 계열회사의 인력수요를 고려하여 그룹차원에서 근로자들을 일괄하여 채용한 후, 이들을 각 계열회사에 배정하고 그 후에는 그룹기획조정실이 매년 각 계열회사별로 인력의 수요를 파악하여 잉여인원을 다른 계열회사로 전출시키는 등 인사관리를 시행하여 왔다. 이 사건의 원고는 1986. 2.경 대학을 졸업하고 대우그룹에 채용되어 대우캐리어 주식회사에 배치되어 근무하던 중 1990. 3.경 회사의 방침에 따라 대우조선공업주식회사로 전출명령을 받았으나 위 전출명령을 거부하였고, 이에 대우캐리어는 원고를 해고하였다. 이러한 해고의 정당성이 다투어진 사안에서 대법원은 다음과 같이 판시하였다.

「근로자를 그가 고용된 기업으로부터 다른 기업으로 적을 옮겨 그 다른 기업의 업무에 종사하게 하는 이른바 전적(轉籍, 원심판결은 “계열회사간의 전출”이라고 표현하고 있다)은, 종래에 종사하던 기업과 간의 근로계약을 합의해지하고 이적하게 될 기업과 간에 새로운 근로계약을 체결하는 것이거나, 근로계약상의 사용자의 지위를 양도하는 것이므로, 동일 기업 내의 인사이동인 전근이나 전보와 달라, 특별한 사정이 없는 한 근로자의 동의를 얻어야 효력이 생기는 것인바, 사용자가 근로자의 동의를 얻지 아니하고 기업그룹 내의 다른 계열회사로 근로자를 전적시키는 관행이 있어서 그 관행이 근로계약의 내용을 이루고 있다고 인정하기 위하여는, 그와 같은 관행이 기업사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나, 기업의 구성원이 일반적으로 아무런 이의도 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여 기업 내에서 사실상의 제도로서 확립되어 있지 않으면 안된다. 사실관계가 원심이 확정한 바와 같다면, 소론과 같이 대우그룹 내 계열회사간의 전적이 20여 년간 계속 시행되어 왔고 현존 관리직사원의 30% 이상이 위와 같이 전적된 경력을 가지고 있다고 하더라도, 사용자가 당해 사원의 동의를 얻지 아니하고 일방적으로 다른 계열회사로 전적시키는 관행이 규범적인 사실로서 명확히 승인되었거나 사실상의 제도로서 확립되어 있다고 단정하기 어렵다.」(밀줄 필자)

이 사건에서 대법원이 근로자 동의 없이 이루어진 전적관행의 구속력이 부정한 배경은 전적의 유효요건 자체를 매우 엄격하게 보고 있기 때문이라고 생각된다. 즉 대법원은 전적은 종래에 종사하던 기업과 사이의 근로계약을 합의해지하고 이적하게 될 기업과 사이에 새

로운 근로계약을 체결하는 것이거나 근로계약상의 사용자의 지위를 양도하는 것이므로, 동일기업 내의 인사이동인 전근이나 전보와 달라 특별한 사정이 없는 한 근로자의 동의를 얻어야 효력이 생긴다고 보고, 이러한 동의를 갈음할 정도의 구속력 있는 관행으로서의 전적관행의 성립을 부정한 것이다. 또한, 위 판결은 구속력 있는 노사관행의 성립요건으로 노사관행이 당사자들의 합의 제기 없이 '사실상 제도'로 받아들여 질 것을 요구하여 구속력 있는 노사관행의 성립의 가능성을 매우 좁게 보고 있다.

3.2 특별상여금 지급 관행 : 대법원 1999. 9. 3. 선고 98다34393 판결 (광주상공회의소 사건)

사용자의 급여규정에 의하면 공로가 있다고 인정하는 직원에 대하여는 회장이 특별상여금을 지급할 수 있도록 규정되어 있고, 실제로 이 규정에 따라 1992년부터 매년 12월에 계속적·정기적으로 월급의 100% 상당을 지급해 온 특별상여금의 임금성이 문제된 사안에서, 대법원은 다음과 같이 판시하였다.

「급여규정에 의하더라도, 특별상여금은 회장이 특히 공로가 있다고 인정하는 직원에 대하여 지급할 수 있다고만 규정되어 있을 뿐, 구체적으로 그 지급기준, 지급액수, 지급시기 등에 관하여는 아무런 규정이 없어 그 지급이 확정되어 있다고 보기 어려운 데다가, 실제로도 1986년 이전에는 특별상여금이 지급되었다고 볼 자료를 찾아볼 수 없고, 1987년에 처음으로 월 급여액의 30%가 지급되었고, 1988, 1989년에는 지급된 바 없다가, 1990년도에 다시 30%를 지급한 다음, 1991년도에는 2회에 걸쳐 도합 120%, 1992년부터 1994년까지 3년간은 12월에 100%씩 지급되다가 다시 중단되고, 그 지급 명목도 구구한바, 이러한 사실관계 아래에서라면, 그 지급기준과 지급명목 등에 비추어 특별상여금이 월 급여의 100%씩 매년 12월에 계속적·정기적으로 지급되고 있다거나, 그러한 관례가 성립되었다고 보기는 어렵다.(대법원 1994. 5. 24. 선고 93다4649 판결 등 참조).」(밑줄 필자)

대법원은 위 판결에 특별상여금 지급이 수차례 반복되었다고 하더라도 그러한 특별상여금의 지급기준이나 지급액수, 지급시기 등이 일정하지 않다는 이유로 노사관행으로 성립되었다고 보기 어렵다고 판시하였다.

3.3 임금인상분 차액의 소급지급 관행 : 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000다50701 판결(한국전력공사 사건)

한국전력공사는 1961년 이래 1996년까지 매년 임금인상을 내용으로 하는 단체협약을 체결하고 이러한 단체협약의 내용에 따라 보수규정을 개정하면서, 재직 중인 직원들에게는 직전 연도의 보수규정에 따라 지급된 임금과 같은 기간 동안 개정된 보수규정에 따라 지급되었을 임금과의 차액을 추가로 지급하여왔고, 퇴직한 직원들에게도 이러한 임금인상분 차액은 물론 이러한 차액을 지급받았더라면 이를 기초로 산정되었을 퇴직금액과의 실제로 지급된 퇴직금액의 차액을 추가로 지급하여 왔다. 그런데 1997년에는 단체협약을 체결하고 이에 따라 보수규정을 개정한 후 재직 중인 근로자들에게는 종전과 같이 임금인상분 차액을 소급하여 지급하였으나, 당시 이미 퇴직한 직원들에게는 임금인상분 차액과 퇴직금인상분 차액을 지급하지 아니하였다. 이에 퇴직한 직원들은 한국전력공사를 상대로 임금인상분 차액의 소급지급 노사관행을 근거로 차액분의 지급을 구하였는바, 이 사안에 관하여 대법원은 다음과 같이 판시하였다.

「원심이 내세우는 노사관행이 어떠한 사실에 근거한 것인지는 분명하지 아니하나, 그것이 만약 피고가 재직 근로자들에게 임금인상분 차액을 소급하여 지급한 사실을 말하는 것이라면, 이는 노사 간에 체결된 단체협약 및 이에 따라 개정된 보수규정에 따른 것이 분명하므로, 거기에 무슨 노사관행이 성립할 여지가 없다. 또한 원심이 내세우는 노사관행이 피고가 이미 퇴직한 근로자들에게까지 임의로 임금인상분 및 퇴직금인상분 차액을 추가 지급하여 준 사실을 말하는 것이라면, 그것은 노동조합 또는 근로자 집단과 사용자 사이에 있었던 사실이 아니라, 이미 퇴직한 근로자들과 사용자였던 피고 공사 사이에 있었던 외부적 사정에 불과하므로, 그로써 노동조합 또는 근로자 집단과 사용자 사이의 노사관행이 성립할 수도 없는 것이다. ……(중략)…… 그런데 기업의 내부에 존재하는 특정의 관행이 근로계약의 내용을 이루고 있다고 하기 위하여는 그러한 관행이 기업 사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나 기업의 구성원에 의하여 일반적으로 아무도 이의를 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여져서 기업 내에서 사실상의 제도로서 확립되어 있다고 할 수 있을 정도의 규범의식에 의하여 지지되고 있어야 하나(대법원 1993. 1. 26. 선고 92다11695 판결 참조), 단체협약이 그 본래적인 성질에 있어서 협약 당사자인 구성원에게만 그 효력이 미치는 점, 이미 퇴직한 근로자는 원칙적으로 노동조합과 사용자 사이의 단체교섭에 간여하거나 이를 조종·선동할 수 없는 점(노동조합및노동관계조정법 제40조) 등에 비추어 보면, 위와 같은 내용의 노사관행은 그 성립요건인 규범의식 자체가 인정될

수 없는 것이고, 기록상 달리 위와 같은 규범의식이 있었다고 볼 자료가 없으므로, 이를 전제로 하여 원심이 실시한 조건부채권의 성립을 단정할 수도 없다.」(밑줄 필자)

대법원은 위 판결에서 퇴직자에 대한 임금인상분 차액 지급에 대해 근로자와 사용자 사이에 문제가 아니라 이미 퇴직한 근로자와 사용자 사이의 외부적 사정이라고 보아 노동관행의 성립을 부정하였다. 나아가 노사관행의 성립요건으로 '규범의식'이라는 요소를 요구하여 노사관행을 관습법과 유사하게 이해하는 태도를 보이고 있다.

3.4 노조사무실 경비지원 관행 : 대법원 2014.2.27. 선고 2011다109531 판결(한국철도공사 사건)

전국철도노동조합과 한국철도공사의 2006년도 단체협약과 2010년도 단체협약에는 각각 '공사는 조합활동을 위한 사무실을 제공한다.'라는 규정이 있었으며, 한국철도공사는 전신이었던 철도청 시절부터 전국철도노동조합이 설립된 1945년경 이후 노동조합 사무실을 제공하면서 그에 부수하는 전기시설의 이용에 따른 전기요금도 부담하여 왔다. 그러던 중 한국철도공사는 2009년 실시된 종합감사에서 노동조합 사무실의 전기요금을 부담하는 것이 노동조합의 운영비를 원조하는 부당노동행위에 해당될 수 있따는 지적을 받은 후 노동조합 측에 전기요금을 부담하지 않겠다고 통지하였고, 2009. 12.분부터 노동조합 사무실의 전기요금 납부를 중단한 사안에 관하여 대법원은 아래와 같이 판시하였다.

「원고와 피고가 체결한 2006. 4. 1.자 구 단체협약 제13조 제1항과 2010. 5. 14.자 신 단체협약 제11조 제1항은 각각 '공사는 조합활동을 위한 사무실을 제공한다.'라고 규정하고 있을 뿐 전기요금 등 그 운영비에 대하여 아무런 정함이 없는 바, 이러한 단체협약 조항의 문언적인 의미, 노동조합 및 노동관계조정법의 규정 내용, 철도청이 전기요금을 지원해 오게 된 경위 및 국가기관에서 공기업으로 전환된 이후 피고가 취한 입장과 행동 등의 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고와 피고가 체결한 위 각 단체협약 조항에서 정한 '사무실의 제공'에 사무실이라는 공간적인 시설과 사회통념상 그 안에 일반적으로 비치되는 책상, 의자, 전기시설 등 부대시설의 제공을 넘어 운영비의 성격을 지닌 전기요금의 지급까지 포함된다고 해석할 수는 없을 뿐만 아니라, 전기요금지원 관행이 피고 내에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되었다거나 사실상의 제도로서 확립되어 있다고 할 수 있을 정도의 규범의식에 의하여 지지되고 있었다고 보기도 어렵다.」

위 판결에서도 대법원은 구속력 있는 노사관행의 성립요건으로 노사관행이 ‘규범의식’에 의하여 지지되고 있을 것으로 요구하면서 노조사무실 경비지원 관행의 구속력을 부정하였다.

3.5 근무시간 중 조합활동 관행 : 대법원 2003. 8. 22. 선고 2001두 5767판결

종래 상급단체의 화합행사 또는 교육행사의 참석을 근무시간 중의 조합활동으로 보고 이를 허용하여 온 관행이 있었던 사업장에서, 노동조합의 근무시간 중 상급단체의 대의원대회 등의 참석을 위한 조합활동 허용 요청을 거부한 사안에 관하여 대법원은 다음과 같이 판시하였다.

「원심은 채용한 증거들을 종합하여 피고보조참가인(이하 ‘참가인’이라 한다)의 이 사건 근무시간 중 조합활동의 보장 요청과 이에 대한 원고의 협조 거부 사실, 이 사건 채심판정의 경위, 근무시간 중의 조합활동에 관한 단체협약 규정, 참가인의 근무배려 요청과 이에 대한 원고의 조치 내역, 사전 협의의 방법 등에 관한 사실을 인정한 다음, 판시와 같은 이유로 전국민주철도지하철노동조합연맹(이하 ‘민철노련’이라 한다)의 대의원대회 및 중앙위원회는 단체협약 제 15조 제1항 제4호에 규정된 상급단체의 화합행사 또는 교육행사에 해당되거나, 그렇지 않다 하더라도 원고와 참가인 사이에서의 위 각 회의의 참석을 근무시간 중의 조합활동으로 보고 이를 허용하여 온 관행이 성립되어 있었다고 판단하였는 바, 앞서 본 법리에 따라 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하여 이를 수긍할 수 있고, 거기에 노동관행에 관한 법리를 오해한 위법이 없다. 따라서 이 부분은 상고이유의 주장은 이유 없다.」

위 사안에서 대법원은 상급단체의 화합행사 또는 교육행사의 참석에 관한 노사관행의 성립을 인정하였는바, 이러한 관행의 구속력의 인정요건으로 ‘규범의식’등의 요건을 요구하지는 않고 있다.

3.6 무사고 포상금 지급 관행 : 대전지방법원 2008. 5. 20. 선고 2007가단53553 판결

1998년 이전부터 매년 주주총회에서 무사고 3년 이상의 근로자들에 대한 포상금지급결의를 하고 이에 기해 무사고 포상금을 지급해 왔으며(지급금액 등이 확실하게 밝혀지지는 않

았다), 1998년부터 2006년까지 사이에도 3년 무사고 운전자에게 10만원을 지급하는 것을 기준으로 3년 이상의 무사고 운전경력자 모두에게 1년 5만원씩 추가한 금액을 무사고 포상금으로 지급해 온 관행이 있는 운수회사가 2007년 주주총회를 개최한 이후 무사고포상금의 지급기준을 5년 무사고 운전자에게 20만원을 지급하는 것을 기준으로 지급기준을 일방적으로 변경한 사안에서 대전지방법원은 다음과 같이 판시하였다.

「위 규정상으로는 원고들이 지급받아 온 무사고 포상금이 피고 회사의 재량에 맡겨진 듯 되어 있으나, 피고 회사가 적어도 1998년부터는 예외없이 매년 3월 주주총회 직후 정기적·계속적으로 3년 이상의 무사고 운전자들에게 무사고 기간에 비례하여 일정액을 지급해 왔음은 위에서 본 바이다. 한편, 그 지급시기나 지급방법 및 지급액수 등에 비추어 무사고 포상금 지급은 피고 회사나 그 소속 운전근로자들이 당연한 것으로 받아들여 이미 피고 회사 내에서 사실상의 제도로서 확립되어 있다고 볼 수 있을 것이다. 결국, 무사고 포상금 지급은 사용자의 호의에 의하여 은혜적으로 지급된 것이 아니라 노동관행으로 형성된 근로의 조건으로서 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지는 것으로 보아야 한다. ……(중략)…… 무사고 포상금 지급은 노동관행으로서 피고 회사의 운전근로자들에게 적용되고 있는 근로조건의 내용인 바, 피고 회사가 위에서 본 바와 같이 포상금 지급기준을 변경함으로써 3년 이상의 무사고 운전자 중 변경 기준에 따라 포상금 지급대상자로 선정되지 못한 원고들에게는 근로조건이 불이익하게 변경된 경우에 해당된다. 단체협약에 따르면 임금 및 근로조건에 관한 사항은 단체교섭사항일뿐더러, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 결성되어 있는 피고 회사에서는 근로조건을 불이익하게 변경하기 위해서 노동조합의 동의를 받아야만 한다.」(밑줄 필자)

이 사건은 기존에 성립된 노사관행의 폐기 내지 변경의 유효성이 다투어진 사안이다. 노사관행의 폐지의 방법으로는 ① 노사 간의 합의, ② 자연적인 소멸, ③ 일방당사자의 고지 등 3가지 형태를 상정할 수 있을 것인바, 실제로 노사관행의 폐지가 문제되는 것은 ③의 경우라고 할 것이다. 본 판결은 사용자가 기존의 노사관행을 근로자에게 불리하게 변경하기 위한 요건을 마치 취업규칙의 불이익한 변경과 유사하게 “근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 결성되어 있는 피고 회사에서는 근로조건을 불이익하게 변경하기 위해서 노동조합의 동의를 받아야만 한다.”라고 판단하였는바, 이러한 판단은 노사관행의 법적 성질을 불문의 취업규칙으로 이해하는 전제에서 있는 것으로 생각된다.

3.7 하계체력단련비와 추석상여금 지급 관행 : 대구지방법원 2014. 2. 21. 선고 2013가합8360 판결

대구문화방송은 1988년부터 2009년까지는 각 임금협약에 따라 매년 하계체력단련비 및 추석특별상여금을 특별상여금조로 지급하였고, 임금협약이 체결되지 아니한 2010년부터 2012년까지도 이러한 특별상여금을 지급하여 왔으나, 2013년에는 이사회 결의를 통하여 하계체력단련비 및 추석특별상여금을 지급하지 아니하였다. 이에 대구문화방송의 직원들이 회사를 상대로 2013년 하계체력단련비와 추석상여금 100%인 약 6억 7천만원의 지급을 구하는 소송을 제기한 사안에서 대구지방법원은 다음과 같이 판시하였다.

「피고와 이 사건 대구지부는 1999.년부터 2009.까지 매년 임금협약을 체결함에 있어 특별상여금 300%를 지급하기로 규정한 사실, 피고는 2000.부터 2012.까지 재직 중인 직원을 대상으로(2012.7.25. 지급한 하계 체력단련비는 제외) 각 해의 설(구정) 또는 추석 전에 설 세찬비 또는 추석 특별상여금 명목으로 각 100%(기본급 + 직책수당)에 해당하는 특별상여금을 지급한 사실(다만, 2005. 하계 체력단련비는 50%만, 2009. 특별상여금은 2009.12.31. 200%만 지급하였다), 특히 피고와 이 사건 대구지부 사이에 임금협약이 체결되지 않은 2010.부터 2012.까지도 역시 위와 같이 설 세찬비, 하계 체력단련비, 추석 특별상여금으로 각 100%(기본급 + 직책수당)에 해당하는 특별상여금을 지급하였고, 나아가 임금협약이 체결되지 않은 2013.에도 설(구정) 전인 2013.1.31. 100%(기본급 + 직책수당)에 해당하는 설 세찬비를 지급한 사실이 인정되는바, 결국 이 사건 특별상여금은 지급 당시 재직 중인 직원을 대상으로 근로의 대가로서 정기적·계속적으로 지급되고, 그 지급에 관하여 피고와 근로자들 사이에 그 지급이 당연히 여겨질 정도의 관례가 형성되어 노동관행에 의하여 피고에게 지급의무가 있다고 인정되는 임금에 해당한다고 할 것이다.」(밑줄 필자)

위 판결에서 대구지방법원은 “그 지급이 당연히 여겨질 정도의 관례”라는 표현을 쓰고 있는 바,¹²⁾ 이는 노사관행을 사실인 관습으로 판단하여 근로계약에 대한 보충적 해석을 하고

12) 이러한 판단은 대법원 1997. 5. 28. 선고 96누15084 판결의 “평균임금 산정의 기초가 되는 임금총액에는 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 지급하는 일체의 금품으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 이으면, 그 명칭 여하를 불문하고 모두 포함되는바, 사용자에게 근로의 대상성이 있는 금품에 대하여 그 지급의무가 있다는 것은 그 지급 여부를 사용자가 임의적으로 결정할 수 없다는 것을 의미하는 것이고, 그 지급의무의 발생근거는 단체협약이나 취업규칙, 급여규정, 근로계약에 의한 것이든 그 금품의 지급이 사용자의 방침이나, 관행에 따라 계속적으로 이루어져 노사간에 그 지급이 당연한 것으로

있는 것으로 이해 된다. 다만, 위 사안에서 ‘규범의식’등을 노사관행의 성립요건으로 요구하지는 않고 있어, 노사관행의 성립가능성을 다소 넓게 이해하는 것으로 생각된다.

IV. 결론

위에서 살펴본 바와 같이, 우리나라의 판례는 노사관행을 기업사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나 기업의 구성원에 의하여 일반적으로 아무도 이의를 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여져서 기업 내에서 사실상의 제도로써 확립되어 있다고 할 수 있을 정도의 규범의식에 의하여 지지되고 있는 관행을 의미하는 것으로 이해하여 왔다. 즉 판례는 구속력 있는 노사관행을 기본적으로 민법 제106조의 사실인 관습으로 인식하고 있다. 판례는 이러한 이해를 전제로 일정한 노사관행이 구속력을 갖기 위해서는 ① 기업사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나, ② 기업의 구성원이 일반적으로 아무런 이의도 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여 기업 내에서 사실상의 제도로써 확립되었음을 전제로, ③ 이러한 관행이 규범의식에 의하여 지지될 것을 요구하고 있는 것으로 이해된다. 한편, 구속력 있는 노사관행의 성립을 부정하는 판결례들은 대부분 특정한 노사관행이 ‘규범의식’에 의하여 지지되었다고 보기 어렵다는 점을 이유로 제기하고 있는 바, 결국 계속적·반복적 사실로서의 관행이 존재하는 것으로 인정되는 경우에도 이러한 관행에 대한 규범의식에 의한 지지가 존재할 경우에만 그러한 관행에 구속력이 인정된다는 것이 판례의 입장이라고 생각되며, 이러한 점에서 판례는 구속력 있는 노사관행의 성립 가능성을 매우 좁게 인정하고 있다고 평가된다.

한편, 판결례가 구속력 있는 노사관행의 요건으로 요구하고 있는 ‘규범의식’이라는 표현은 그 자체가 매우 규범적이라는 점 때문에 노사관행에 구속력이 인정되기 위해서 어느 정도의 규범의식에 의하여 지지될 것을 요구하는가의 물음에 대한 구체적인 기준은 전혀 제시하지 못하고 있다. 노사관행에 구속력이 인정되는지 여부는 그러한 노사관행에 근거하여 근로관계가 규율 및 형성되는가라는 문제와 직결되어 있는 문제이다. 이와 같이 이해관계자의 법률관계의 형성에 직접 영향을 미치는 노사관행의 구속력의 인정여부가 명확한 기준이 없어

여겨질 정도의 판례가 형성된 경우처럼 노동관행에 의한 것이든 무방하다.”라는 판시내용과 거의 흡사하다.

‘규범의식’이라는 모호한 기준에 의하여 결정된다면 이는 법적 안정성의 측면에서 수긍하기 어려운 측면이 있다. 구속력 있는 노사관행의 독자적인 기능적 가치를 고려할 때, 향후 구속력 있는 노사관행의 성립요건에 관한 보다 명확한 기준의 설정이 시급하다고 생각된다.

참고문헌

권오성(2004), “노사관행의 법적 성질에 관한 일고찰,” 변호사, 제34집, 서울지방변호사회.

김재훈(1999), “근로조건 변경의 법리- 불이익변경의 한계를 중심으로,” 서울대학교 박사학위 청구논문.

박수근(2002), “노동관행의 규범성과 단체협약의 소급적 효력,” 노동판례비평, 민주사회를 위한 변호사모임.

菅野和夫(2007), 일본노동법, 이정 역, 법문사.

菊池高志(2004), “勞使慣行,” ヴェリスト 増刊: 労働法の争点, 有斐閣.

浜村彰(2002), “勞使慣行の效力: 商大八戸ノ里ドライビングスクール事件,” ヴェリスト別冊 165號: 労働判例百選(第7版), 有斐閣.

寺井基博(2000), “労働條件の決定・變更と勞使慣行の法理,” 講座21世紀の労働法 第3卷: 労働條件の決定と變更, 有斐閣.

경영관리연구
(제7권 제2호)

An Article on Labor Practice

Chio kwang-hwa*

Gong yu-joo**

In February 2014, The Supreme Court of Korea (SCK) has judged that Korea Railroad Corporation (KRC) is not legally obligated to pay for the electricity used in the labor union's office.

Even though KRC has supported the electric fess for the union's office last 60 years, if the collective agreement between parties have not made to include the electric fees other than offering an office, this could not be admitted as a labor practice.

This case could be acknowledged as an implied agreement since KRC has consistently supported for the electric fees without an objection for decades. However, SCK has judged the case as is not the labor practices. Meanwhile, the labor practice was admitted in a similar case stating that the corporation has an obligation of payment when the special production incentives were offered regularly, consistently and uniformly to the workers. The former case has not been admitted it as a labor practices whereas the latter has been. As it concerned, SCK causes a confusion on labor practices by judging differently for each cases.

It is important to extend the range of acknowledge and apply an adequate standard to judge which kind of continuous conduct is satisfied for the requirements of labor practices.

Key words : labor practices, labor custom, Conventional Law, De Facto Custom, Practice

* Certified public labor attorney, E-mail: cgh7000@hanmail.net

**Master's Degree Candidate, Dept. of Law, Sungshin Women's University,
E-mail: charming8023@gmail.com